

1500951-78.2020.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2140552/2020 - DISE-

DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 11814140 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 142/20/102 - DISE-

DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 2140552 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500951-78.2020.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500951-78.2020.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2140552/2020 - DISE-

DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 11814140 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 142/20/102 - DISE-

DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 2140552 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN BIBIANO SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra WILLIAN BIBIANO SILVA (fls. 80/81), qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pela suposta prática do seguinte fato delituoso:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de junho de 2020, no período da tarde, na Rua Americanópolis, nº 42, bairro Pirajussara, nesta Cidade de Embu das Artes, WILLIAN BIBIANO SILVA, qualificado a fls. 08, trazia com ele e guardava, para fins de tráfico, 135 porções de cocaína (70,2g) e 26 porções de maconha (41,2g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (fl. 80)

A denúncia foi recebida em 21.01.2021 (fls. 83/84).

Regularmente notificado, o denunciado apresentou defesa prévia, por intermédio de defensor nomeado, refutando o teor da denúncia e arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 139/141).

Em não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento para a presente data (fls. 148/149).

Na data aprazada, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais (conforme termo de audiência).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão punitiva procede.

A materialidade delitativa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 1), no boletim de ocorrência (fls. 2/4), no auto de exibição e apreensão e no laudo de constatação provisória das substâncias apreendidas (fls. 11/12 e 18/20), despontando, ainda, do laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 96/98). Depreende-se de tais elementos cognitivos que foram apreendidas em poder do acusado 135 porções de cocaína, com peso líquido de 70,2g, e 26 porções de maconha, com peso líquido de 41,2g, além de R\$ 14,00 em espécie. O exame químico-toxicológico atesta que as substâncias entorpecentes apreendidas são causadoras de dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, conforme a Portaria nº 344/1998 da Secretária da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. A autoria também é certa, exsurgindo da prova vocal produzida nos autos, sob o crivo do contraditório.

Tanto em solo policial (fls. 5 e 6), quanto em juízo (mídia audiovisual da audiência), os dois policiais civis que realizaram a diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, ouvidos na condição de testemunhas, apresentaram versões harmônicas, dando conta da ocorrência dos fatos narrados na denúncia. Marcio Aparecido Vian Mourão relatou que: no dia da ocorrência, acompanhado do colega Alan, deslocaram-se até o local dos fatos, ponto já conhecido pelo tráfico de drogas; visualizaram o acusado em atitude suspeita, segurando uma lata; percebendo que seria abordado, o imputado dispensou a lata no chão; durante a abordagem, vistoriaram o interior da lata dispensada, onde encontraram os entorpecentes apreendidos, afora o valor em espécie; indagado, o réu admitiu informalmente a prática do comércio ilícito de estupefacientes.

O policial civil Alan Fernandes Dias reproduziu, em essência, a narrativa de seu colega Márcio, enaltecendo que: após breve incursão, observaram o acusado em atitude de possível mercancia; com este foram apreendidas maconha e cocaína, de fora parte um pouco de dinheiro; o increpado admitiu a traficância.

A despeito da negativa em solo policial (fl. 8), em juízo o réu confessou integralmente a prática delitativa (mídia audiovisual da audiência).

Da confissão judicial do acusado, aliada aos seguros depoimentos prestados pelos agentes públicos na senda extrajudicial, emerge quadro probatório convincente e bastante para lastrear o édito condenatório.

Ressalto não ser necessária a constatação da venda e distribuição propriamente dita da droga para que o agente seja responsabilizado criminalmente, bastando à configuração do tipo misto alternativo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 que ele traga consigo ou guarde narcóticos destinados ao comércio ilegal. Na lição de LUIZ FLÁVIO GOMES:

Consuma-se o crime com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de tráfico. Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (por exemplo, expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa. (Lei de Drogas comentada artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de 23.08.2006, 3. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 185/186). Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Mencionada figura dita a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente, cumulativamente, seja (i) primário (não reincidente); (ii) de bons antecedentes (não ostente condenação criminal anterior transitada em julgado); (iii) não se dedique às atividades criminosas (desenvolva algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada ao crime, sendo o crime de tráfico a ele imputado no processo um evento isolado em sua vida); e (iv) não integre organização criminosa (associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013).

No que diz especificamente com o requisito negativo da não dedicação a atividades criminosas, CLEBER MASSON pontua que "(...) a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso pode (e deve) ser utilizada pelo magistrado como circunstância apta a afastar a figura privilegiada, pelo fato de indicar a dedicação do agente a atividades criminosas, nada obstante seja vedado utilizar tais fatores como circunstância judicial desfavorável, na dosimetria da pena-base, uma vez que não caracterizam maus antecedentes." (Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019).

Comungando do mesmo entendimento, RENATO BRASILEIRO DE LIMA ressalva que, "conquanto não seja possível a utilização de inquéritos policiais e processos penais em curso para se concluir que o acusado tenha maus antecedentes, admite-se a utilização desse critério para formar a convicção de que o réu se dedique a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Não se trata de avaliação de inquéritos ou processos penais para agravar a situação do réu condenado por tráfico de drogas, mas sim uma forma de se afastar um benefício legal, porquanto existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique a atividades criminosas, sendo inquestionável que, em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado. Ademais, como os princípios constitucionais devem ser interpretados de forma harmônica, não merece ser interpretado de forma absoluta o princípio da inocência, de modo a impedir que a existência de inquéritos ou ações penais impeçam a interpretação em cada caso para mensurar a dedicação do réu em atividade criminosa. Assim não o fazendo, conceder o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para aquele que responde a inúmeros processos penais ou seja investigado é equipará-lo com quem numa única ocasião na vida se envolveu com as drogas, situação que ofende o princípio também previsto na Constituição Federal de individualização da pena." (Legislação criminal especial comentada: volume único. 9. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 1.085). (Negrítei).

Esse entendimento doutrinário tem ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do EResp 1.431.091/SP em 14.12.2016, pela 3ª Seção, sob a relatoria do eminente Ministro Felix Fischer, ocasião em que se obtemperou que "o crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, LXII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação da proteção deficiente".

A partir desse precedente, a Corte Superior de Justiça vem majoritariamente reafirmando, por meio de suas duas turmas com competência criminal, o posicionamento no sentido de que a existência de persecuções penais pendentes de definitividade é apta a afastar o redutor em análise quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva (no ponto: HC 450.153/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.08.2018; AgRg no AREsp 1.251.694/SP, 5ª Turma, rel. Min. Felix Fischer, j. 05.08.2018; HC 442.254/RS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.05.2018; AgRg no AREsp 999.769/RS, 6ª Turma, rel. Min. Néfi Cordeiro, j. 06.11.2017; e AgRg no REsp 1.678.417/GO, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Ribeiro, j. 17.04.2018).

Essa compreensão também prepondera no âmbito das Câmaras de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (confirmam-se, por todas: Apelação Criminal nº 1501744-74.2018.8.26.0567, 7ª Câmara, rel. Des. Otavio Rocha, j. 13.06.2021; Apelação Criminal nº 0000118-89.2018.8.26.0019, 15ª Câmara, rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. 02.06.2021; Apelação Criminal nº 1527069-30.2020.8.26.0228, 2ª Câmara, rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 24.05.2021; Apelação Criminal nº 1510569-83.2020.8.26.0228, 12ª Câmara, rel. Des. Vico Mañas, j. 12.05.2021; e Apelação Criminal nº 1502243-35.2019.8.26.0628, 1ª Câmara, rel. Des. Diniz Fernando, j. 19.04.2021).

Na espécie, consta da Folha de Antecedentes (fl. 115) e do sistema e-SAJ que está em trâmite outra persecução penal em desfavor do acusado (autos nº 1501578-82.2020.8.26.0628). Apesar de ser tecnicamente primário, o réu já teve outro envolvimento criminal, pela suposta prática de delito idêntico, tendo sido preso em flagrante logo após ser beneficiado com a liberdade provisória nestes autos. A reiteração de condutas delituosas, ainda que não decorra de condenações transitadas em julgado, demonstra a dedicação a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição de pena em foco.

Logo, ausentes excludentes de ilicitude e dirimentes de culpabilidade, e não descortinadas causas de extinção da punibilidade, a responsabilização criminal do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena aplicável a ele, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, as circunstâncias estatuídas pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A natureza (cocaína e maconha) e a quantidade não portentosa das drogas não ensejam maior reprovação penal. De outro vértice, não há maiores informações sobre a personalidade e a conduta social do agente.

Já, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas no art. 59 do CP, verifico que: a culpabilidade é normal à espécie delitativa; o réu não ostenta condenações criminais anteriores transitadas em julgado, e a persecução penal em andamento não pode ser consideradas para exasperar a pena-base (Súmula nº 444 do STJ); o motivo é inerente ao elemento subjetivo do delito; as circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo penal, no aspecto objetivo, não justificando maior reprimenda; está-se diante de crime vago, não se cogitando de comportamento de vítima específica.

À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no piso de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea perante a autoridade judicial (art. 65, III, "d", do Código Penal). Não diviso, por outro lado, agravantes.

A fim de não desrespeitar o patamar estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal, deixo de atenuar a pena anteriormente dosada (Súmula nº 231 do STJ), a qual remanesce inalterada.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição e/ou de aumento, ao que torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor mínimo unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, porquanto não há informações sobre a situação econômica do réu (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena corporal, em vista do quantum da reprimenda e das circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP).

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, mercê da quantidade da sanção corporal imposta (arts. 44, I, e 77, caput, do CP, a contrario sensu).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu WILLIAN BIBIANO SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de (a.1) 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e (a.2) e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

O acusado respondeu a este processo em liberdade, foi apenado com sanção privativa de liberdade a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, cenário incompatível com a prisão preventiva (vide, por todas, a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in Código de Processo Penal Comentado - 19. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 792, encampada pelo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, esposado no Informativo nº 554 da sua jurisprudência), de modo que, na ausência de pedido expresso da acusação, remanesce hígido o direito do acusado de recorrer também em liberdade (art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal), salvo se por outro motivo estiver preso.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), uma vez que se cuida de crime vago, que vulnera bem jurídico difuso, e não houve pedido expresso da acusação nesse tocante.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Contudo, a respectiva exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da dicção conjunta dos arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC, pois ora lhe concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.

Declaro o perdimento dos bens e valores eventualmente apreendidos em poder do agente em favor da União, o que faço com supedâneo no art. 63, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.343/2006. Quanto aos entorpecentes, oficie-se à autoridade policial para que proceda à incineração - caso ainda não tenha sido realizada.

Expeça-se certidão de honorários em favor do nobre patrono nomeado no valor máximo previsto na tabela vigente.

Sobrevindo o trânsito em julgado: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (c) oficie-se ao IIRGD para cadastro dos antecedentes; (d) expeça-se a documentação necessária para a execução das penas; e (e) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo das multas, intimando-se, em seguida, o acusado para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do CP).

Oportunamente, arquivem-se definitivamente os autos, promovendo-se as baixas nos registros.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Embu das Artes, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA